



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. חבאני גדעון,
2. חבאני אילנה,

באמצעות ב"כ: עו"ד האס בעז

נגד

הנתבע:

קומימי בנימין,

באמצעות ב"כ: עו"ד ברק ארנון

פסק דין

לפניי תביעה שעניינה סילוק יד וקבלת דמי שימוש ראויים.

רקע עובדתי נדרש והצדדים להליך

1. עסקינן בבית משותף ברחוב ישראל ישעיהו 21 א' כפר סבא הידוע כחלקה 232 בגוש 7621 (להלן - "הבית המשותף"). בבית המשותף שתי דירות ועל פי צו רישום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 08.08.1957, הוצמדו לכל אחת מהדירות מחצית מסך הזכויות ברכוש המשותף בחלקים שווים (להלן - "הצו").

2. התובעים, חבאני גדעון וחבאני אילנה, הם בעלי זכות וחוכרי משנה של תת חלקה 1 ומחצית מכלל הזכויות ברכוש המשותף (להלן - "התובעים"). הנתבע, קומימי בנימין, הוא בעל זכות וחוכר משנה של תת חלקה 2 וגם לו מחצית של כלל הזכויות ברכוש המשותף (להלן - "הנתבע"). "הקרן הקיימת לישראל" היא הבעלים הרשום של החלקה.

תמצית טענות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות התובעים בקצרה

1. בין הצדדים נחתם הסכם שיתוף בשנת 1986 (נספח ד' לכתב התביעה) (להלן- "ההסכם") בו חילקו בניהם את המגרש בחלקים שווים.
2. לפני שנים רבות הנתבע השתלט על שטח של 17 מ"ר השייך להם ועשה בו שימוש ייחודי תוך מניעת שימוש מצדם. חרף הבטחותיו, הנתבע לא פינה את השטח שבמחלוקת עליו השתלט ומכתב התראה שנשלח לנתבע בתאריך 21.07.2019 לסילוק ידו לא נענה ולכן הוגשה התובענה.
3. מכיוון ששטחו הכולל של החלקה עומד על 1,047 מ"ר, כעולה מנסח רישום הבית המשותף (להלן- "נסח הרישום") והואיל ומודד מוסמך קבע כי גודל הרכוש המשותף שבו משתמש הנתבע, חורג ממחצית זכויותיו ב - 17 מ"ר, קרי, 541 מ"ר במקום 523 מ"ר כפי שמורה נסח הרישום, עליו לסלק את ידו משטח זה שהוא כנטען חלק מזכויותיהם הקנייניות של התובעים המוצמד לדירתם (להלן- "שטח המחלוקת").
4. בין הצדדים הייתה הסכמה בלחיצת יד כי הנתבע ישתמש בשטח שבמחלוקת אך ישיבו לשימוש התובעים לאחר פטירת אימו.
5. מפת מדידה מתאריך 02.09.2019 (נספח ב' לכתב התביעה) מעידה כי חלקו של הנתבע במגרש עומד על 541 מ"ר ואילו חלקם של התובעים נאמד בכ - 506 מ"ר בו בעת שכל אחד מהצדדים אמור להחזיק ב-523 מ"ר שהם מחצית מ - 1,046 מ"ר, כלל הרכוש המשותף כמצוין בנסח רישום מקרקעין (ראה נספח א' לכתב התביעה), וכעולה מהסכם השיתוף.
6. הנתבע אינו חולק על כך שהוא משתמש ומחזיק ייחודי בשטח שהוא יותר ממחצית חלקו ברכוש השותף. השטח שבמחלוקת אינו בנוי והחזרת שימוש לתובעים, לא תפגע כלל בבית הנתבע הקיים בסמוך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. הערכת שמאי שצורפה לתובענה אמדה את דמי השימוש בשטח המחלוקת בעשר שנים האחרונות בסך של 12,982 ₪ אותם דורשים התובעים לקבל כדמי שימוש ראויים.

8. התובעים שילמו דמי היוון על מחצית זכויותיהם במגרש הכוללים את השטח שבמחלוקת שאינו ברשותם עקב מחדלי הנתבע.

9. לא עלה הנטל בידי הנתבע להוכיח כי נחתם בין הצדדים הסכם כלשהו אחר שהעניק לו את הזכויות להשתמש ברכוש המשותף השייך להם כשבשלו ומשתמש שלא כדין בזכות הקניינית שאינה שלו ולכן, על הנתבע לשאת במלוא הוצאותיהם ולשלם דמי שימוש בגין השימוש שעשה.

טענות הנתבע בקצרה

10. דין התביעה להידחות מחמת התיישנות ושיהוי רב שכן הוא משתמש בשטח שבמחלוקת מזה 34 שנים.

11. למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בתובענה, שכן עניינה בפן הקנייני שבתחום סמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי (במאמר מוסגר יצוין כי הנתבע לא חזר בהמשך ההליך על טענתו זו).

12. קיים הסכם חתום נוסף שנחתם בין הצדדים לאחר ההסכם שצורף לכתב התביעה (להלן-"ההסכם הנוסף" או "ההסכם השני"), שהורה על אופן החלוקה הקיימת כיום ברכוש המשותף ומשום כך דין התביעה להידחות על הסף.

13. אין מחלוקת כי במשך למעלה מ-34 שנים הנתבע משתמש בשטח המחלוקת, אך לדידו, שימוש זה עתיד להקנות לו אפשרות לרישום זיקת הנאה לטובתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. יש לראות בשתיקת התובעים במשך השנים כמי שזנחו את דרישתם ותביעתם לקבל חזרה את השטח שבמחלוקת. מה עוד שהתובעים מעולם לא פנו למשטרה בתלונה על הסגת גבול.

15. היה על התובעים לצרף להליך גם את אשת הנתבע, שכן היא בעלת זכויות מכוח חוק יחסי ממון, ומשלא נעשה כן דין התביעה להידחות.

16. הנתבע הוכיח את קיומו של הסכם שני, שנכרת לאחר הסכם השיתוף. במסגרת ההסכם השני, ויתרו התובעים לנתבע על השטח שבמחלוקת. קבלת התביעה יהיה משום עידוד הפרת הסכמים.

17. קבלת התביעה תביא להריסה של בית המגורים של הנתבע, דבר שאין לאפשר.

18. התובעים לא קיימו את תקנות סדר הדין ואף בפועל לא צורפו ראיות לתצהיר התובעים. התובעים לא הביאו עדים רלבנטיים להוכחת טענותיהם.

מהלך הדיון בקצרה

19. בתאריך 25.01.2021 הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם התובעים חתום על ידי התובע 1, גדעון חבאני שהוגש גם בשם אשתו, התובעת 2, אילנית חממי (להלן- "התובעת 2" ו"תצהיר עדות ראשית מטעם התובעים").

20. התיק הועבר לטיפול לאחר מינויה של כב' המפקחת אושרת ארפי מוראי, למפקחת בכירה על רישום מקרקעין באזור ת"א. מכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן- "חוק המקרקעין") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע.

21. בתאריך 21.03.2021 הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע. הראשון חתום על ידי הנתבע והשני חתום על ידי אשתו, הגב' איילה קוממי אף על פי שלא הייתה צד לתובענה (להלן- "תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/634/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. בתאריך 12.04.2021 התקיים דיון הוכחות שבו נחקרו, מלבד בעלי הדיון, העדים הנוספים הבאים: עו"ד יצחק פרוינד שבפניו חתמו הצדדים על ההסכם, הגב' שרה שליוינסקי מזכירתו של עו"ד פרוינד, ינון כברה, חתנם של התובעים והגב' קוממי אילנה – אשת הנתבע (להלן-"פרוטוקול דיון הוכחות").

23. בהחלטה מתאריך 04.05.2021, התבקשו הצדדים להגיש עותק של מפת מדידה מוגדלת שצורפה כנספח ב' לכתב התביעה וכדי לבחון אפשרות לסיום הסכסוך ונקבע מועד לביקורי בבית המשותף להתרשמות ישירה.

24. בתאריך 18.05.2021 ערכתי ביקור בבית המשותף כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען והוצע על ידי מתווה פשרה נוסף ליישוב הסכסוך.

25. בתאריך 10.10.2021 התקיים דיון נוסף במטרה לנסות לסייע לצדדים לסיים המחלוקת בהסכמה, אלא שניסיון זה לא צלח (להלן-"פרוטוקול דיון מתאריך 10.10.2021").

דיון והכרעה

למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעות שעילתן סילוק יד ודמי שימוש ראויים

26. אף על פי שבדיון קדם המשפט לא עמד הנתבע על טענת הסמכות (עמ' 2 ש' 13 לפרוטוקול הדיון), ואף לא חזר על טענה זו בסיכומיו, ומשכך יש לראותה כטענה שנזנחה [ע"א 2950/07 סולימאן נ' מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל, פסקה 32 (נבו 26.10.2009)], מצאתי לנכון להתייחס אליה שכן, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלול לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [רע"א 6500/19 גבריאלי נ' אשד, בפסקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית,
פסקה כ"א (21.3.2016).

27. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף
72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי
דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), המורה לאמור:
"א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם
לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף
1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז
מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני
רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג
לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה
לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי
בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

ג) האמור בסעיפים קטנים א) ו-ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה
מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת
בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר
לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור
להכרעת בורר.
(ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

28. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה
המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד,
מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72
לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה
הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם [ראו רע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/634/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון
כרמיאל בע"מ, פסקה 20, (נבו 17.03.2016).**

29. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין, בין היתר, הסמכות לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לרכוש המשותף בבית המשותף; סמכות המקבילה לסמכות בית משפט מוסמך. כך בענייננו, עת בכתב התביעה עתרו התובעים להורות לנתבע לסלק ידו משטח הרכוש משותף בבית המשותף, משפלש אליו ותופס בו חזקה ייחודית שלא כדין בפניי, התקיים התנאי הראשון.

30. בהתייחס לזהות הצדדים, קובע סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין). די באמור כדי לקבוע כי מתקיימים התנאים במצטבר מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה דנן.

31. סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, מסדיר את דוקטרינת "סמכות נגררת" כפי שהיא מקבלת את ביטוייה במשפט הישראלי וקובע כי אם הובא עניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר.

32. כשם שלבית משפט השלום סמכות שבגררא לדון במסגרת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין גם כן במחלוקת לעניין הבעלות בה, כך רשאי המפקח לדון בגררא בשאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין שלפני (ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסון, בפסקה 23 (04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. כך גם לגבי הסעד של דמי שימוש ראויים. בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 3/98 **חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני** (נבו, 28.2.1999) נפסק כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך על פי סעיף 72(ב) לחוק (אותו סעיף המקנה לו סמכות מקבילה לפסוק בעילת הסגת גבול), לפסוק גם פיצויים בגין הסגת גבול.

34. סמכות המפקח על רישום מקרקעין לפסוק דמי שימוש ראויים בתובענה שעילתה הסגת גבול היא משום שיקולי יעילות הדיון ומדיניות שיפוטית. שכן, אין זה ראוי שאגב דיון בתיק בסוגיית סילוק יד, לא ידון הטריבונל הדן ממילא בתיק, גם בסוגיית דמי השימוש הראויים הנובעים מהסגת הגבול, לרבות פיצוי בגין נזק ממון הנובע מעילת הסגת הגבול (285/10 **נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפרי** (נבו 18.01.2011); 398/15 **דגש. חניונים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בשד' המגינים 53, חיפה**, בפסקאות 78-80 (נבו 26.08.2020); 104/19 **א.ג.ת.ד. בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב הסיבים 48 וברחוב הנשיא 75-73**, בפסקאות 12-15 (נבו 02.01.2020).

35. יודגש כי עילת הסגת גבול ועילת דמי שימוש ראויים הן שתי עילות תביעה נפרדות. עילת דמי השימוש הראויים מקורה בדיני עשיית עושר ולא במשפט. משכך גם נפסק שאין צורך לבקש היתר לפיצול סעדים כאשר מוגשת תביעה נפרדת של דמי שימוש ראויים, בנפרד מסילוק היד (רע"א 1156/02 **עבד אל סלאם חיר נ' עבד אל סלאם חיר** (נבו, 11.5.2003)).

36. עם זאת אין המפקח רשאי לדון בדמי שימוש ראויים כעילה עצמאית ויחידה כאשר היא אינה כרוכה עם עילת הסגת הגבול וסילוק יד. בפעמים שבהן נקבע כי המפקח מוסמך לפסוק דמי שימוש, הדבר היה רק כאשר נושא דמי השימוש נדון יחד ובמשולב, וכפועל יוצא מעילת סילוק היד. במקרה כזה קיימת הצדקה כי הטריבונל אשר ממילא דן בתיק, יפסוק גם בסוגיית דמי השימוש הראויים ולא יטריח ערכאה נוספת לדון בסוגיה שנגזרת מאותה מערכת עובדתית [ראו לעניין זה פסק דינה של כב' המפקחת אסתי שחל בעניין (המפקח על המקרקעין נתניה) 182/17 **נציגות הבית המשותף ברח' אריק לביא 3, נתניה נ' חברת קרן פז לבניין בע"מ**, בפסקה 13 (נבו 27.05.2020)]. אך בשעה שהעילה היחידה שנותרת לדיון כעילה עצמאית, עניינה דמי שימוש ראויים שמקורה בדיני עשיית העושר, אין למפקח על רישום מקרקעין, הסמכות העניינית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדון בה [(המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 294/11 נציגות הבית המשותף רחוב
עמנואל הרומי 13 תל אביב נ' אוזן (נבו 01.08.2011)].

37. ובמיושם לענייננו - עילות התביעה לפניי הן סילוק יד ודמי שימוש ראויים,
וכמפורט לעיל, בידי הסמכות העניינית לדון בעילות אלה, לצורך הכרעתו,
אידרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת זכויותיהם הקנייניות בשטח
שבמחלוקת. אלא שכאמור בנושא שאלת הזכויות הקנייניות, אדון בגררא אגב
שאלת סילוק היד.

**דין טענת ההתיישנות שהעלה הנתבע להידחות-לנוכח הוראת סעיף 159 (ב)
לחוק המקרקעין ולנוכח היותה של הסגת הגבול עוולה מתמשכת**

38. בחוק המקרקעין נקבע כי תביעה ביחס לזכות רשומה היא חסינה לחלוטין
מהתיישנות מתוך מגמה להפוך את הרישום בלשכת רישום המקרקעין
לאמין, סופי ומוחלט. סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין מגדיר התיישנות דיונית
בסכסוכים בין בעלי זכויות בתביעות לקיום זכות במקרקעין לאמור:

**"חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות
במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות
שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה".**

39. סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין קובע כי הוראות חוק ההתיישנות לא יחולו על
תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים. מטרתו של סעיף זה היתה "לחסן
זכות במקרקעין מוסדרים מפני טענת התיישנות העומדת בסתירה
לרישומים שבפנקסי המקרקעין. בכך עברה מן העולם תפיסת הדין הקודם
שהכירה בהתיישנות הן כטענת הגנה בתביעה לסילוק יד, ובמקרים
מסוימים אף כאמצעי לרכישת הבעלות במקרקעין..." (ע"א 520/96 חוסין נ'
מיר, פ"ד נד(3) 487, 494 (2000), מפי כב' השופט מצא). עוד נקבע כי " **המדובר בחריג לדיני ההתיישנות, שממנו עשוי ליהנות רק בעל זכות
במקרקעין מוסדרים שדאג לרשום את זכותו ובכך 'הזהיר' את כולי עלמא
כי זכותו שוב אינה עשויה להתיישן**" (ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד
נז(5) 49, 61 (2003), מפי כב' השופט מצא).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. אומנם, סעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 (להלן - "חוק ההתיישנות"), קובע כי התקופה בה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה ועניינה מקרקעין מוסדרים, עומדת על 25 שנה, וסעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום בו נולדה עילת התובענה. אך כידוע, במקרה של התנגשות בין דין כללי לבין דין מיוחד, האחרון הוא שגובר (Lex specialis derogat generali) [דנ"א 1595/06 **עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח-תקווה**, בפסקה 28 (21.3.2013); ע"א 7957/13 **מדרך עוז בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב**, בפסקה 73 (נבו 1.11.2018)]. לכן, הוראות סעיף 159(ב) גוברות על ההסדר בחוק ההתיישנות, בקובען שהחל ביום כניסת חוק המקרקעין לתוקפו (1.1.70) אין עוד תחולה לחוק ההתיישנות בכל הנוגע למקרקעין מוסדרים [ע"א 520/96 **אחמד עבדאלעזיז חוסין נ' מרים מיר**, פ"ד נד(3) 487 (נבו 07.08.2000); ע"א 6631/10 **אמנה מוסטפא אבו סביה נ' עזבון המנוח חוסין סעיד עזאיזה** (27.02.2013)].

41. עוד יש לזכור כי בהתאם להוראות סעיף 81 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, הליך במסגרתו הוסדרו המקרקעין "מאפס" את תקופת ההתיישנות. כך שרישום זכויות לאחר הליך הסדר זכויות במקרקעין מבטל כל זכות סותרת, לרבות של מי שזכאי היה לטעון לזכויות במקרקעין במהלך הליך ההסדר ולא עשה כן. (סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 162/87 **כמאל יוסף סמארה אמארה נ' סרוה עיסא יוסף**, מה(5) 533 (1991)).

42. לכך יש להוסיף שאף אם המקרקעין הוסדרו לפני כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין (1.1.1970), טענת התיישנות יכולה להישמע רק על ידי מי שחזקתו במקרקעין החלה לפני 1.3.1943 ונמשכה 25 שנה לפחות לפני יום 1.1.1970 [ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 631/82 **רשות הפיתוח נ' יחזקאל להבי**, תשמ"ה(1) 003 (1984)].

43. וכן, הלכה פסוקה היא שהסגת גבול במקרקעין היא עוולה מתמשכת, במובן זה שעילת לסילוק יד בגינה, מתחדשת מיום ליום, ואינה מתיישנת [ע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3137/15 עיריית חיפה נ' קהילת ציון אמריקאית, פסקה 11 (נבו 21.5.2018);
ע"א 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת
ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פסקה 38 (נבו
9.10.2018); ע"א 1551/19 פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית
שיתופית בע"מ נ' גובר, פסקה 12 (נבו 15.1.2020).

44. ובמיושם לענייננו - המקרקעין מושא התביעה, הם מקרקעין מוסדרים,
הנתבע עצמו טוען בכתב ההגנה (סעיף 4) כי הוא מחזיק בקרקע מזה 34 שנים,
קרי מאז שנת 1986, ולאחר כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין, אשר קבע כי
אין התיישנות לגבי מקרקעין מוסדרים כפי שהוסבר לעיל. מה עוד שעילת
סילוק יד הנובעת מהסגת גבול אינה מתיישנת, ומשכך טענת ההתיישנות
שהעלה הנתבע נדחית.

**דין טענת השיהוי להידחות - הנתבע לא הוכיח כי עמד בתנאים להוכחת טענת
השיהוי**

45. דוקטרינת השיהוי במשפט האזרחי מוגבלת למקרים חריגים ונדירים, ומטילה היא
נטל כבד על הטוען לה וכי חלוף הזמן אינו נתון בלעדי ואינו נתון בעל חשיבות
עצמאית בעת בחינת השיהוי. בפסיקה נקבעו פרמטרים נוספים, מלבד חלוף הזמן,
השלובים זה בזה אותם נדרש להוכיח לשם קבלת טענת שיהוי, ואלו הם: יצירת מצג
בדבר ויתור על זכויות התביעה ושינוי לרעה במצבו של הנתבע עקב השיהוי בהגשת
התביעה. תנאי נוסף שהוזכר בהקשר זה הוא התנהלות בחוסר תום לב מצד
המשתתף בהגשת התביעה. ומכל מקום, גם כאשר תנאים אלו מתקיימים, עדיין
לערכאה הדיונית שיקול דעת להכריע בדבר המשמעות שראוי להעניק לטענת
השיהוי במקרה הספציפי שלפניה. [ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה
הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד נז 433
(5) בעמ' 445 – 446 (2003); ע"א 5262/08 מילגד בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר
פס"כ"א (נבו 29.7.2010)]. עוד נקבע כי כשמדובר בתביעה לגבי זכות קניינית, יירתע
בית המשפט מחסימתה בטענת שהוי, אף אם התקיימו התנאים דלעיל [ע"א
9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM (נבו, 17.12.18)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. ובמיושם לענייננו - הנתבע לא הוכיח כי התובעים ויתרו או מחלו על זכותם הקניינית בשטח שבמחלוקת. ויתור או מחילה על זכות כזו, צריכים להיעשות על סמך מצג ברור ומפורש, שכאמור לא הוצג לי, אלא להיפך - במהלך השנים התובעים לא ישבו בחיבוק ידיים, ואף דאגו לכך שייחתם בין הצדדים במסגרתו עוגנו זכויות הצדדים. בנוסף, לא הוכח על ידי הנתבע כי בשל השיהוי הנטען, שינה הוא את מצבו לרעה, בהסתמכו על מצג התובעים. מכאן אני מגיע למסקנה כי טענת השיהוי בדומה לטענת ההתיישנות שהעלה הנתבע, נדחית אף היא.

דין התביעה לסילוק יד להתקבל - בין הצדדים נחתם הסכם השיתוף לפיו הקרקע תחולק בין הצדדים שווה בשווה, ומנגד לא הוצג על ידי הנתבע הסכם אחר המאוחר להסכם השיתוף המראה אחרת

47. פרק ה' לחוק המקרקעין, מגדיר את יחסי השיתוף בנוגע למקרקעין שהם של כמה בעלים. סעיף 29 לחוק המקרקעין, שכותרתו "הסכם שיתוף" קובע כי הסכם חלוקה או הסכם שיתוף ניתן לרישום ועם רישומו הוא יחייב גם צדדי ג', ובלשונו: "(א) הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן - הסכם שיתוף) ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר". כך שההסכם מחייב את הצדדים אף אם לא נרשם. וכן, לא אחת נקבע בפסיקה כי טענה של צד ג' להעדר תחולה של ההסכם בשל אי רישומו, כפופה לעקרון תום הלב ועל בית המשפט להיווכח כי צד ג' לא ידע או לא היה צריך לדעת על אודות הסכם השיתוף או החלוקה בעת רכישת זכויותיו [ע"א 48/16 ציון דהאן נ' יגאל שמחון (נבו) 9.8.2017; ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385].

48. עוד ידוע הכלל שקיבל ביטוי בסעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאני, הדורש כי טענה נגד מסמך בכתב הנוגע להתחייבות, חוזה או הלוואה, תוכח "במסמך בכתב" [ע"א 62/52 מוריס דיין נ' יעקב א. אבוטבול, ט 1047 (1955)]. כך שאין להסתפק בעדות בעל-פה שיש בה לסתור מסמך בכתב, ולכל הפחות יש להציג מסמך אחר שדי בו "כי יבטיח - כשמצרפים אליו עדות אחרת -



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את הוכחת ההסכם בדרך מהימנה" [ע"א 65/49 משה פריזלר נ' פריץ יוסי, ה
1951)878].

49. כמו כן, את ההסכם אשר נחתם בין הצדדים, יש לפרש בהתאם לדיני החוזים.
לכן ככלל, משחתמו הצדדים על הסכם, עומדים הם בחזקתם שהסכימו לכל האמור
בו, לשבט או לחסד [ע"א 1/84 נתן נ' סטרוד, פ"ד מב(1) 661, 670 (19.4.1988); ע"א
16/80 לולו נ' סלומון, פ"ד לו (4), 70, 74-75 (18.9.1983)]. לשון החוזה היא "כלי
הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס
לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל (11.5.2006); ע"א 8080/16
עמודי שחף בע"מ נ. פינקל יוסף, בפסקה 12 (8.8.2018)].

50. ובמיושם לענייננו - המחלוקת כאמור היא לגבי שטח של כ-17 מ"ר אשר
לגביו התובעים טענו כי הנתבע פלש אליו, הסיג גבול ועשה בו שימוש ייחודי
על-אף שהוא שייך לתובעים.

51. התובעים הציגו נסח רישום (נספח א' לכתב התביעה) המעיד על זכויותיהם
בחלקה 232 בגוש 7621. שטחה הכולל של החלקה עומד על 1,047 מ"ר. הן על
פי נסח הרישום והן על פי צו הרישום הוצמדו לשתי תתי החלקות שבבעלות
הצדדים מחצית שווה וזהה של 31/62 חלקים מהרכוש המשותף, וכך למעשה
לכל צד זכויות קנייניות לשימוש בשטח של 523 מ"ר (מחצית מגרש).

52. החלקה בכללותה אינה רגולארית והיא דמויית משולש. תת חלקה 1
שבבעלות התובעים נמצאת בחלקה הדרומי ואילו תת חלקה 2 שבבעלות
הנתבע, ממוקמת בחלקה הצפוני של החלקה. להלן חלקו הרלבנטי של
התרשים שהופקד בלשכת רישום המקרקעין עם צו הרישום שבו ניתן להבחין
במבנה המשולש של חלקה 232, הבתים של שני הצדדים והקו שחילק במקור
והצמיד את הרכוש המשותף לכל תת חלקה.

חלקה 232 כפי שמופיעה בתשריט צו הרישום של הבית המשותף :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



53. בתאריך 10.02.1986, נחתם בין התובעים לבין הנתבע הסכם שיתוף (צורף כנספח ד לכתב התביעה), אשר במסגרתו הסדירו ביניהם הצדדים את יחסי השיתוף בכל הנוגע לחלקה ולרכוש המשותף (ראו ה"והואיל" החמישי בעמוד הראשון). במסגרת ההסכם, הסכימו הצדדים בין השאר, על חלוקת הרכוש המשותף ביניהם, "**בחלקים שווים ביניהם**" (ראו ה"והואיל" הרביעי בעמוד הראשון להסכם), כאשר "**לכל צד הזכות לחזקה ושמוש בלעדיים בחלקו בחלקה**" (סעיף 5 להסכם), תוך הקמת גדר גבול בין החלקות ותיקון הצו לרישום הבית המשותף בהתאם לחלוקה (סעיף 11 להסכם).

54. אומנם, בניגוד להתחייבות החוזית בין הצדדים, ההסכם לא דווח או נרשם ואף התרשימים על פיהם בוצעה החלוקה או מפת המדידה שבוצעה על ידי המודד דאז לא הוצגו אף הם. אך כאמור, אין בכך כדי לגרוע מתוקף ההסכם ביחס לצדדים החתומים עליו, ובענייננו התובעים והנתבע, במיוחד לאור לשונו הברורה של ההסכם אשר אינה מאפשרת מקום לפרשנות אחרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/634/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. המוצא לדיון בפניי הם נתוני הרישום, ועיקרם הוא השטח שבמחלוקת דמוי משולש בתשריט המדידה של הבית המשותף, וההסכם בכתב שבין הצדדים שלא הוכחש על ידי הנתבע, אם כי נטען על ידו שקיים הסכם נוסף ו"שני". בכתב הגנתו ולאורך חקירתו, לא הכחיש את טענת התובעים לגבי השטח שבמחלוקת, ואף לא צורפה על ידו מפת מדידה (פרוטוקול דיון ההוכחות, עמ' 48 ש' 19-21), שיהיה בה כדי לסתור את מפת המדידה שצירפו התובעים לתביעתם, אלא טען לאורך כל ניהול ההליך כי נחתם הסכם נוסף אחר בו הסכימו התובעים לבניית הגדר כפי שהיא כיום - אך טען שאינו בידיו.

56. אלא שכאמור, עדותו של הנתבע בעל-פה, גם שאני מצרף לה עדותה של אשתו, אין בה די כאשר היא באה לסתור מסמך בכתב. לכך יש להוסיף כי הנתבע גם לא הצליח להסביר מה בדיוק התמורה שניתנה לטענתו לתובעים בשם ויתורם על השטח שבמחלוקת במסגרת ההסכם השני, כאשר לטענת אשתו בחקירתה הנגדית, לא הייתה כל תמורה בגין הויתור הנטען (פרוטוקול דיון ההוכחות, עמ' 49 ש' 26-27). הנתבע ניסה אומנם לבסס את טענתו על ידי העדת עדים חיצוניים שלטענתו הכירו את המסמך השני, אך הדבר לא עלה בידו, שכן אלו לא אישרו את דבר קיומו של הסכם נוסף (עדותו של עו"ד פרוינד וכן עדותה של גב' שליונסקי בעמודים 4-7 לפרוטוקול דיון ההוכחות). משכך אינני מקבל את טענת הנתבע לפיה נחתם הסכם נוסף.

57. לכך יש להוסיף כי גם העובדה שהנתבע השתמש בשטח שבמחלוקת על בסיס קבוע ובמשך שנים, אינה מקימה לו חסינות מפני תביעה לחדול מכך. אין בהימנעות התובעים מלהגיש תובענה לסילוק ידו מהשטח במחלוקת במשך השנים, כדי להוות הסכמה פוזיטיבית שכן זכות שימוש לעולם אפשר לחזור ממנה (ראה עש"א 36094-01-11 פנינה הופמן נ' נציגות הבית המשותף ברח' ארלוזורוב 188 ת"א פורסם בנבו 08.05.2011).

58. לא מצאתי גם לקבל את טענתו של הנתבע לעניין זיקת הנאה שלטענתו נוצרה לו מכוח השנים. סעיף 5 לחוק המקרקעין מגדיר זיקת הנאה כך: "זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם",



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/634/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואילו הנתבע מבצע בשטח שבמחלוקת שימוש ייחודי, שאי אפשר לראות בו ממילא כזיקת הנאה (ע"א 700/88 חוה אסטרסאן נ' זאב בן-חורין, מה(3) 720 (1991). וכן, הסמכות לקבוע זיקת הנאה כלשהי מסורה לבית המשפט מחוזי [ע"א (מחוזי ירושלים) 6576/05 אסתר שמעון נ' רות רחמוס גבעון (נבו) 29.03.2006].

59. לאור כל אלו, דין התביעה לסילוק ידו של הנתבע מהשטח שבמחלוקת להתקבל.

התובעים זכאים לדמי שימוש רק לתקופה של חמישה חודשים - ממשלוח מכתב ההתראה ועד ליום הגשת התביעה

60. זכאות לדמי השימוש, מתגבשת מכח סעיף 1(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט - 1979 (להלן - "חוק עשיית עושר") הקובע כי "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן - הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן - המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה" [ע"א 588/87 אליעזר כהן ואח' נ' צבי שמש, פד מה(5) 297 (1991); ע"א 889/75 "דרים" בע"מ נ' "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, לא(2) 020 (1973)].

61. סעיף 33 לחוק המקרקעין שכותרתו "תשלום בעד שימוש", קובע כי "שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים, לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש".

62. דמי שימוש ראויים, משקפים את נזקיו של בעל הקרקע מחד גיסא, ואת עשיית העושר של הזוכה מאידך גיסא [ע"א 891/95 זידאני נ' אבו אחמד, פ"ד נג(4) 769, 775-776 (1999)].

63. סעיף 2 לחוק עשיית עושר קובע כי בהתקיים שתי חלופות, רשאי בית המשפט לפטור באופן מלא או חלקי מחובת דמי שימוש ראויים, ובלשון הסעיף: "בית המשפט רשאי לפטור את הזוכה מחובת ההשבה לפי סעיף 1, כולה או מקצתה, אם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/634/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ראה שהזכיה לא היתה כרוכה בחסרון המזכה או שראה נסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי צודקת. " כאשר בהתאם לפסיקה, נתון לבית המשפט שיקול דעת רחב לשקול מגוון של שיקולים לרבות התנהגות הצדדים במהלך השנים ותום ליבם [ע"א 9631/05 דוד ארד נ' מדינת ישראל, בפסקאות 61-62 (נבו 16.12.2010) ; ע"א 546/04 עיריית ירושלים נ' שרותי בריאות כללית, בפסקאות 57-58 (נבו 20.08.2009) ; ע"א 7156/10 חברת הירקון בע"מ נ' מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל, בפסקה 18 (נבו 11.10.2012)].

64. כך למשל, התנהגות שהיוותה בסיס להפחתת דמי שימוש ראויים, הייתה כאשר אחד הצדדים ישב שנים רבות בחיבוק ידיים ואף על פי שידע שהצד השני פלש לנכס שבבעלותו, לא מחה בידו ולא פצה פה. ומשכך נפסק כי יש לחשב את דמי השימוש רק מהתאריך שבו פנה בכתב לראשונה לצד האחר בדרישה לפינוי השטח שתפס, ועד להגשת כתב התביעה [ע"א (מחוזי מרכז) 50271-03-17 מועצה מקומית מזכרת בתיה נ' חנה בתיה דויטש, בפסקאות 97-98 (נבו 20.02.2018)]. שכן שימוש שנעשה בהסכמה - גם אם זו על דרך התנהגות ממנה ניתן להסיק הסכמה מכללא לשימוש - אינו "שלא על פי זכות שבדין" [ראו ת"א (שלום פ"ת) 12577-10-18 מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל נ' עותמאן ריאן (נבו 11.10.2021) והאסמכתאות שם].

65. **ובמיושם לענייננו** - התובעים צרפו הערכת שמאי של מר סער פלד לצורך הוכחת גובה דמי השימוש הראויים עבור השימוש בשטח שבמחלוקת (נספח ו' לכתב התביעה) (להלן - "**השמאות**"). בשמאות הוערכו דמי השימוש לעשר השנים האחרונות והועמדו על סך כולל של 12,982 ₪. כאשר דמי שימוש ראויים לשטח שבמחלוקת לכל שנת 2019, הוערכו בסכום של 1,518 ₪. יצוין כי הנתבע לא הציג שמאות אחרת מטעמו.

66. אלא שהפעם הראשונה, בו מחו התובעים נגד השימוש שמבצע הנתבע בשטח שבמחלוקת, הייתה במסגרת "מכתב ההתראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים" במסגרתו נדרש הנתבע להחזיר את השטח המחלוקת, אשר נשלח לנתבע בתאריך 21.07.2019 (סעיף 22 לתצהיר התובעים ונספח ה' לכתב התביעה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/634/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

67. התובעים אף אישרו בחקירתם הנגדית כי הסכימו לכך שהנתבע יעשה שימוש בשטח שבמחלוקת משום שלא רצו לפגוע באימו המבוגרת, כל עוד הייתה בחיים (סעיף 19 לתצהיר התובעים ; עמ' 8 ש' 45-47 וכן עמ' 14 ש' 16-17), כאשר גם לאחר שנפטרה בשנת 2003, לא פנו לנתבע כשלטענתם הסיבה הייתה שלא היה להם כסף לעו"ד כדי לעשות זאת (עמ' 14 ש' 1-2 לפרוטוקול דיון הוכחות). וכן, אף התובעים עצמם הודו בחקירתם כי השטח המדויק שבמחלוקת, נודע להם רק לאחר קבלת מפת המדידה מהמודד (נספח ב לכתב התביעה), בספטמבר 2019 (עמ' 19 ש' 47-48 לפרוטוקול הדיון).

68. כך ששימוש הנתבע בשטח שבמחלוקת הגיע לסיומו רק עם גילוי דעתם של התובעים במכתב ההתראה מטעם עורך דינם כפי שפורט לעיל. לפיכך התובעים זכאים לקבל דמי שימוש ראויים רק בגין התקופה שבה עשה הנתבע שימוש בהסכמה מכללא מהמועד שבו הודיעו לו כי עליו לפנות ולהחזיר את השימוש, קרי מועד שליחת מכתב ההתראה ועד לתאריך הגשת התביעה.

69. לפיכך, אני קובע כי על הנתבע לשלם לתובעים דמי שימוש רק בגין חמישה חודשים - מתאריך משלוח מכתב ההתראה עד להגשת התביעה, (מחודש יולי 2019 ועד נובמבר 2019). מכיוון שהשמאות חישבה סך של 3,036 ₪ לכל שנת 2019, סך דמי השימוש בגין חמישה חודשים, יעמוד על 1,265 ₪.

הביקור במקום המחיש כי החזרת השטח שבמחלוקת לידי התובעים לא יביא להריסת בית המגורים של הנתבע

70. בתאריך 18.5.2021 ערכתי ביקור בחצרות הבית המשותף בנוכחות הצדדים, כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען לגבי השטח ברכוש המשותף שבמחלוקת. במסגרת הביקור הצעתי מתווה לפשרה, שלא התקבל בסופו של דבר על ידי הצדדים.

71. במהלך הביקור, נוכחתי לראות כי ניתן להחזיר לשימוש התובעים את השטח שבמחלוקת באופן מהיר ובכך להחזיר לאיזון את חלוקת השטחים המשותפים בהתאם להסכם, וכפי שמופיע בתרשים שצורף לצו רישום הבית המשותף בפגיעה מינימלית, שאין בה כדי להרוס את בית המגורים של הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ראו גם פרוטוקול דיון ההוכחות עמ' 42 ש' 12-15). לפיכך טענת הנתבע לפיה סילוק היד והריסת הגדר, יגרמו להריסת ביתו, נדחית.

טענות הנתבע בקשר עם אי-מילוי התקנות מצד התובעים, אין בהן כדי לדחות את התביעה, ולכל היותר יש להתחשב בכך במסגרת הוצאות ההליך

72. אכן צודק הנתבע כי על-אף שבגוף תצהיר התובעים ישנה הפנייה לנספחים, לא צורפו נספחים כלשהם לתצהירם. בכך למעשה, התנהלו התובעים בדרך שאינה תקינה.

73. אלא שהנספחים אליהם הפנה תצהיר התובעים, היו בדיוק אותם נספחים שצורפו על ידם לכתב התביעה (ראו החלטתי בעמ' 10 לפרוטוקול דיון הוכחות) כך שאומנם יש בכך טעם לפגם, אך לא היה בכך כל דבר מפתיע (ראו פרוטוקול דיון ההוכחות, עמ' 45 ש' 33-40), ובוודאילא דבר הפוגע בזכויות הדיוניות של הנתבע. וכן, הנתבע חקר ואף הפנה את התובעים בחקירתם הנגדית למסמכים השונים (ראו למשל בעמ' 22 ש' 20-21, עמ' 28 ש' 49-50 לפרוטוקול דיון הוכחות), ומשעה שעשה כן "הכשיר" את הפגם.

74. לפיכך, אינני מוצא כי הפגם שבאי-צירוף נספחים בתצהירי התובעים, הוא פגם שיש בו כדי לדחות את התביעה. עם זאת, יש להתחשב בכל הקשור לכך במסגרת הוצאות ההליך, וכך אעשה.

75. לא נעלמה מעיני טענתו של הנתבע, בקשר לכך שלא הובאו לדיון ההוכחות עדים מומחים מטעם התובעים, לא בקשר למפת המדידה, ולא בקשר לשמאות, ומשכך יש לטענתו להתעלם ממסמכים אלו. אומנם, לפי תקנה 87 (ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018 (להלן-"התקנות") **"בעל דין המגיש חוות דעת של מומחה מטעמו ידאג להתייצבותו לחקירה בבית המשפט, וזאת אם בעל הדין שכנגד הודיע שהוא מוותר על חקירתו."**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/634/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

76. אלא שהתביעה שבכותרת הוגשה בתאריך 21.11.2019, וקדם המשפט התקיים בתאריך 27.7.2020, וכך לאור הוראת תקנה 180 לתקנות, חלות עליה תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, אשר במסגרתן (בתקנה 130 א) נקבעה ברירת מחדל הפוכה לפיה **"ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה שהגיש חוות דעת, יודיע על כך לבית המשפט ולשאר הצדדים שלושים ימים לפחות לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או בתוך שבעה ימים מקבלת חוות הדעת, לפי המאוחר"**. משלא ביקש הנתבע לחקור את המומחים, איני מקבל את טענתו [ראו והשוו ע"א (מחוזי מרכז) 24670-01-19 ורד כהן נ' איי. די.איי. חברה לביטוח בע"מ, בפסקה 14 (נבו 06.09.2019)].

77. לא נעלמה מעיניי גם טענת הנתבע, לפיה דין התביעה להידחות משלא צירפו התובעים להליך את אשתו, גב' קוממי איילה, אשר לטענתו זכויותיה הקנייניות מכוח חוק יחסי ממון, צפויות להיפגע מההליך. אלא שטענה זו דינה להידחות. **ראשית**, כפי שנסקר בהרחבה לעיל בפרק הדן בסמכות העניינית, אשתו של הנתבע אינה רשומה כבעלת זכויות כלשהן בחלקה, ומשכך היא אינה בגדר "בעל דירה" לפי חוק המקרקעין, וממילא היא אינה צד רלבנטי להליך (יוזכר כי אשת הנתבע אף העידה מטעמו בהליך וקולה נשמע במסגרת עדותה). **שנית**, פסק הדין דן בסעד של סילוק יד, ואין בקביעותיו הקנייניות שבגררא, כדי למנוע הבאתה של שאלות קנייניות בעתיד בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ע"א 7510/06 שי תמיר נ' שלוה הסל, בפסקה 14 (נבו 11.10.2010)].

לסיכום

78. לאור המובא לעיל, ולאחר שעיינתי היטב בטענות הצדדים, ובפרוטוקולי הדיון, אני מקבל את טענותיהם של התובעים בקשר לסעד סילוק היד, ולפיכך הריני ליתן צו עשה המורה לנתבע לסלק את מטלטליו ורכושו משטח המחלוקת, להרוס את הגדר (להלן-"הקיר המפריד") שבין תתי החלקות כדי שאפשר יהיה להשיב את המצב לקדמותו וכפי שהיה במועד רישום זכויות הצדדים בלשכת רישום המקרקעין, ובהתאם להסכם השיתוף, על פי ההוראות שלהלן:



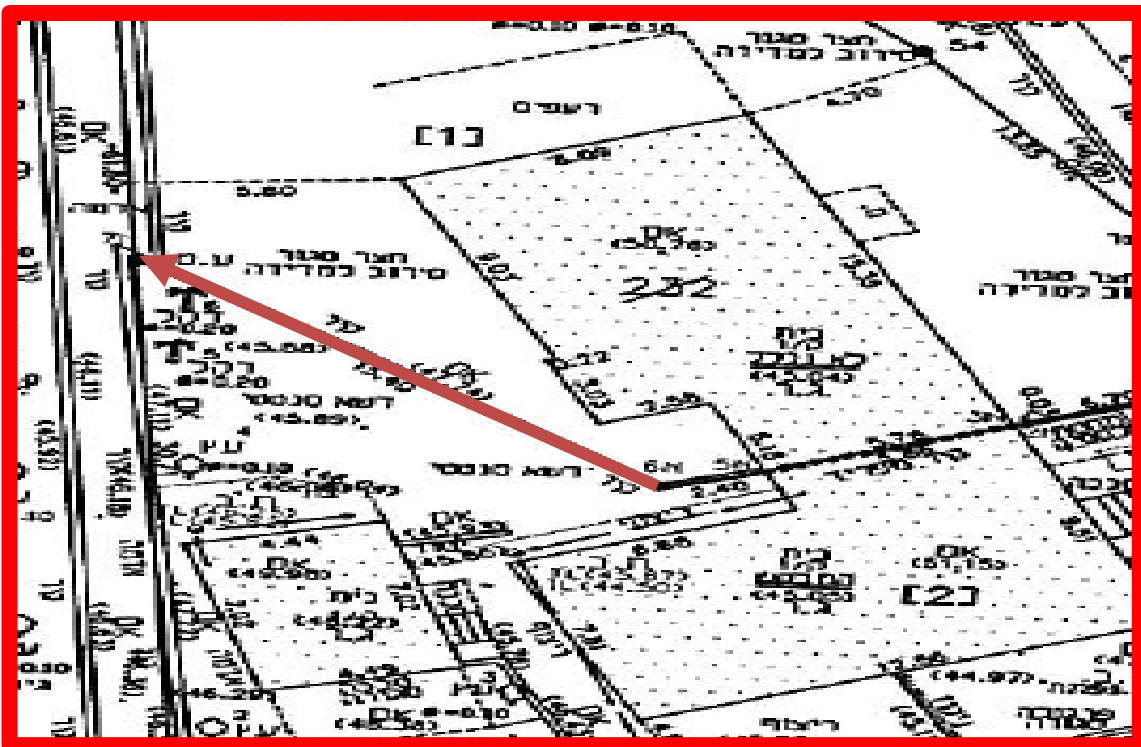
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(א) מפת המדידה שנערכה בתאריך 02.09.2019 על ידי המודד המוסמך מסראוה חוסאם וצורפה לכתב התביעה כנספח ב' – תהיה חלק בלתי נפרד מפסק דין (להלן – "מפת המדידה").

(ב) הקיר המפריד בין תת חלקה 1 לתת חלקה 2 בגוש 7621 שבחלקה 232, מהנקודה המסומנת במפת המדידה כ- N6 ועד לנקודה N7 ייהרס ויוסר ממקומו, כמוצג בתרשים להלן, לכל המאוחר בתוך 60 יום מתן פסק הדין על ידי איש מקצוע מיומן שזו תחום מומחיותו לביצוע עבודות אלו. כל ההוצאות בגין סעיף זה יחולו על הנתבע.



תרשים הקיר המיועד להריסה - מנקודה N6 ועד לנקודה N7 (חץ אדום במפה), על בסיס מפת המדידה

(ג) מייד לאחר הריסת הקיר המפריד וניקוי השטח מההריסות והמטלטלין השייכים לנתבע, יוקם קיר חדש (בצבע לבן) באופן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שיחלק את המגרש בצורה שווה בין הצדדים (להלן- "הקיר החדש"). לשם מיקום מדויק של הקיר החדש, אני ממנה את המודד מר מסראוה חוסאם (להלן- "המודד"), אשר בהתבסס על מפת המדידה שערך, יסמן בשטח את המיקום המדויק שבו ייבנה הקיר החדש באופן שיחלק את המגרש בין הצדדים שווה בשווה, כך שהשטח שבמחלוקת, ולכל היותר 17 מ"ר, יוחזרו לרשות התובעים. שכ"ט של המודד יחול על הנתבע.

(ד) הקמתו של הקיר החדש תסתיים לכל המאוחר בתוך 90 יום ממתן פסק הדין ותבוצע על ידי איש מקצוע שזו תחום מומחיותו ובהתאם למפרט חומרים בכתב ובהתאם לתקנים הישראליים לביצוע עבודות אלו. הוצאות סעיף זה יחולו על הנתבע.

(ה) לא יאוחר מ-14 ימים לאחר גמר עבודות בנית הקיר החדש וצביעתו, יעביר הנתבע לתובעים אסמכתה בכתב מאת איש המקצוע, המאשרת את ביצוע העבודות בהתאם לפסק הדין, ואישור בכתב מאת המודד לפיו בניית הקיר החדש בוצעה במיקום המדויק.

(ו) כל העבודות לעיל יבוצעו בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ותקנותיו. ככל שיהיה צורך של איש מקצוע להיכנס לחצר התובעים לשם ביצוע העבודות לעיל, יאפשרו זאת התובעים ובלבד שהכניסה לחצרם תתואם איתם מראש.

79. כמו כן, בתוך שלושים ימים מהיום, ישלם הנתבע לתובעים סך של 1,265 ₪ בגין דמי שימוש ראויים לתקופה שבין חודש יולי 2019 ועד נובמבר 2019. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מתאריך הגשת התביעה (21.11.2019) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

הוצאות ההליך

80. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו [ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)].

81. תקנה 151(א) לתקנות, קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). במסגרת בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר** (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות, תוך התחשבות בשיקולים הבאים: התנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; בסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

82. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי העניין, ובהתאם לאמות המידה שהותוו בתקנות ובפסיקה, ובשים לב להתנהלותם הדיונית של הצדדים ולמחדלם של התובעים בכל הקשור לתצהירם, החלטתי לחייב את הנתבע, בהוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 9,000 ₪. (סכום זה הוא **בנוסף** לסכום המופיע בסעיף 79 לעיל). הוצאות ההליך ישולמו על ידי הנתבע לתובעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

83. כמו כן, מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין הנני להורות לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על זכויותיו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/634/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של הנתבע, מר בנימין קוממי ת.ז. 57365827, בחלקה 232/2 בגוש 7621.
ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע
עסקאות.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה ביום, 13 בדצמבר 2021 בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה